

1501098-60.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... novamente autuado pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1500514-56.2022.8.26.0599 - fls. 147/151), contrariando a impulsividade e eventualidade necessárias para a caracterização do "tráfico-privilegiado" e evidenciando que faz ele dessa hedionda prática delitativa conduta recorrente em sua vida. Ressalte-se que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501098-60.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000806

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188971/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 19018612 - 02º D.P. PIRACICABA, 2598/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2188971 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON MUNHOZ DE SOUSA

Aos 13 de abril de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: EVERTON MUNHOZ DE SOUSA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GM EVERTON FERREIRA DE JESUS - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC CESAR EDUARDO BOTTENE - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunhas GM EVERTON FERREIRA DE JESUS.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC CESAR EDUARDO BOTTENE, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC CESAR EDUARDO BOTTENE, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu EVERTON MUNHOZ DE SOUSA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "EVERTON MUNHOZ DE SOUSA, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 97/99. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 114), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 118/122), sendo a denúncia recebida (fls. 123/125). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pela fotografia de fls. 25 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 142/144. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O guarda municipal Everton Ferreira de Jesus, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram dois indivíduos parados na esquina da Rua Promissão. Contou que um deles estava numa motocicleta e outro, posteriormente identificado como sendo o ora acusado, em pé, parado, aparentemente entregando algo ao motociclista. Relatou que ao avistarem a guarnição, os indivíduos tentaram empreender fuga, tendo o motociclista tomado rumo desconhecido. Disse que não perderam de vista o réu, que correu sentido a Comunidade Pantanal, porém foi abordado. Afirmou que, durante revista pessoal, em sua posse foram localizadas 36 porções de maconha e 15 eppendorfs de cocaína, além da quantia de R\$ 20,00, acondicionados dentro de uma bolsa pendurada em seu pescoço. Questionado, Everton contou que estava desempregado e que vendia drogas no local para seu sustento. Afirmou que o local onde estava o acusado já era conhecido como ponto de venda de drogas. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal César Eduardo Bottene, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que foi até o local dos fatos, uma biqueira, para comprar drogas para seu uso. Disse que um "moleque" que traficava atendeu o motociclista e em seguida o atendeu. Disse que comprou três porções de cocaína. Alegou que ao chegar a viatura o "moleque" fugiu e jogou a bolsinha que trazia no pescoço no chão, tendo os guardas que o abordaram localizado a tal bolsinha e disseram que lhe pertencia. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, insta ressaltar que, em que pese a alegação do acusado no sentido de que esta no local para comprar drogas para seu uso, é certo que os guardas que o abordaram foram coesos ao afirmar que viram o réu a pé entregando algo para um motociclista, tendo ele sido abordado após se evadir. O guarda foi categórico ao afirmar que ao avistarem o acusado, ele já portava a bolsinha contendo as drogas no pescoço, a qual foi com ele apreendida após sua abordagem. Alias, vale ressaltar que o guarda Everton, na fase inquisitiva, asseverou que não chegaram a perder o réu de vista durante a fuga, até sua abordagem. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente

contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, não se observa circunstâncias agravantes. Na terceira fase, inaplicável o art. 33, §4º da Lei de Drogas, vez que, inobstante a primariedade do réu, é certo que, após ser beneficiado pela liberdade provisória nestes autos, foi ele posteriormente novamente autuado pela prática de tráfico de drogas (autos nº 1500514-56.2022.8.26.0599 - fls. 147/151), contrariando a impulsividade e eventualidade necessárias para a caracterização do "tráfico-privilegiado" e evidenciando que faz ele dessa hedionda prática delitativa conduta recorrente em sua vida. Ressalte-se que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (d.n): AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REINCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRADO DESPROVIDO. (...) III - Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agrado regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Vale citar, outrossim, o mencionado pelo Desembargador Toloza Neto (Apelação nº 0056977-13.2010.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, julgado em 31.01.2012, publicado em 02.02.2012), analisando hipótese de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06: Não resta dúvida, assim, de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houve dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual. Ainda sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de Habeas corpus: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante o paciente seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento com base nas circunstâncias do caso

concreto, as quais levaram a crer que o sentenciado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao cometimento do narcotráfico. 2. Para entender de forma diversa, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 211975 SP 2011/0153576-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2012).

Demais a mais, verifica-se que o acusado ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico quando era adolescente (fls. 102), o que demonstra que está envolvido com esta prática ilícita desde tenra idade. Requeiro, por fim, seja decretado

o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreu de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade,

o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E ainda: "Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.". Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante - embora essa situação não tenha restado demonstrada nos autos, eis que o acusado não foi visto praticando atos que indicassem o comércio de entorpecentes - e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Entretanto, caso não seja acolhida a preliminar suscitada pela Defensoria Pública, QUANTO AO MÉRITO, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Everton, GCM, declarou que não se lembrava da ocorrência. A Juíza leu alguns detalhes da denúncia para a testemunha. A testemunha declarou que estavam em deslocamento pelo local dos fatos quando, ao entrarem na Rua Garça, visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles estava em uma motocicleta. O indivíduo que estava a pé entregava um objeto para o indivíduo que estava na moto. Ao verem a viatura, os indivíduos tentaram se evadir. O indivíduo que estava a pé tentou fugir rumo à Comunidade Pantanal, mas foi abordado. Em revista pessoal, encontraram uma bolsa com o réu, contendo as drogas descritas na denúncia e a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro. O acusado confessou informalmente o tráfico de drogas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O local é conhecido como ponto de tráfico. O réu, em interrogatório, declarou que estava indo comprar entorpecentes para seu consumo pessoal. O traficante, ao ver a viatura, saiu correndo e dispensou a bolsa contendo os entorpecentes. Havia um outro motociclista que também estava comprando drogas. Comprou 03 porções de cocaína. Pagou R\$ 30,00 pelo entorpecente. Quando os Guardas chegaram, o traficante fugiu pela favela e jogou a bolsa com as drogas. Enquanto era abordado por um dos Guardas, o outro pegou a bolsa e disse que ela lhe pertencia. Não portava a bolsa. Não entregou nenhum objeto ao indivíduo da moto. Excelência, o acusado, como visto, nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque as provas reunidas pela acusação se resumem às palavras dos Guardas responsáveis pela prisão do réu. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes

policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Guardas Municipais e da suposta “movimentação suspeita” visualizada, não é possível afirmar que aquelas condutas se tratavam, efetivamente, de um ato de comércio de drogas, eis que o outro indivíduo não foi abordado e tampouco apresentado como eventual comprador das substâncias entorpecentes e/ou testemunha presencial dos fatos. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Caso este E. Juízo entenda não ser possível afastar o pleito absolutório, requer-se, então, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Com efeito, ainda que se entenda que o acusado estava, de fato, com a posse das drogas, deve-se reconhecer que a capitulação do delito dada pelo Ministério Público, qual seja, a do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mostra-se equivocada. Com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Inclusive, ainda que se queira dar total credibilidade à versão dos Policiais, vale observar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Assim, pugna a defesa, caso não haja a absolvição, pela desclassificação do delito, com as consequências legais. Acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º – Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação

da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida" (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que ele foi solto durante o processamento do feito e inexistente de fato concreto que autorize, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

EVERTON MUNHOZ DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 14h57min, na Rua Garça, nº 209, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 15 (quinze) "ependorfs" de cocaína em pó, pesando aproximadamente 3,6g (três gramas e seis decigramas), e 36 (trinta e seis) porções de maconha, pesando cerca de 40,8g (quarenta gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram o acusado em atividade típica de tráfico, eis que estava com uma bolsa no pescoço e entregou algo a um motociclista que se evadiu do local ao perceber a aproximação da viatura. EVERTON também tentou empreender fuga correndo sentido à comunidade "Pantanal", porém os agentes públicos foram em seu encalço e o abordaram. Em busca pessoal, foram localizados na posse do réu, especificamente na bolsa que ele trazia em seu pescoço, os entorpecentes retro descritos e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Indagado, EVERTON confessou aos guardas municipais a prática delitiva.

O réu foi notificado (fls. 144) e apresentou defesa preliminar (fls. 118/122), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 123/125).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e

interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pela fotografia de fls. 25 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 142/144, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu se valeu do direito de permanecer em silêncio. (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Alegou que foi até o local dos fatos para buscar drogas e viu um rapaz numa moto, que estava sendo atendido pelo moleque que fazia o tráfico. Asseverou que, na sequência, comprou três porções de cocaína, por R\$ 30,00. Então, os guardas chegaram e o moleque que vendia correu, tendo dispensado a bolsinha que estava no pescoço dele numa escada. Afirmou que foi abordado pelos guardas, que pegaram a bolsinha e falaram que era sua, o que não é verdade.

A negativa do acusado foi infirmada pela prova produzida.

Com efeito, o guarda municipal Everton relatou que estavam em deslocamento pelo local e, na rua da Garça, avistaram dois indivíduos, um numa motocicleta e outro a pé, o qual aparentemente entregava algo para o da motocicleta. Asseverou que o motociclista se evadiu ao notar a aproximação da viatura e o que estava a pé tentou se evadir para a comunidade "Pantanal", mas foi abordado. Atestou que, com ele, encontraram uma bolsinha pendurada no pescoço, na qual havia 36 invólucros de erva que aparentava ser maconha e quinze eppendorfs de pó branco aparentando ser cocaína, além de R\$ 20,00. Indagado, o réu confessou que estava no comércio de entorpecente, eis que estava desempregado e vendia para manter seu sustento e seu vício. Aduziu que não o conhecia anteriormente, mas o local dos fatos já era conhecido como ponto de tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Enfim, o fato de os guardas municipais terem flagrado o acusado em atitudes típicas da traficância, vindo a localizar quinze porções de cocaína e trinta e seis porções de maconha em poder dele, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduzem à certeza quanto à autoria.

A quantidade e diversidade do entorpecente apreendido e a forma como estava acondicionado, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico e às circunstâncias da apreensão, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado. Assim, reduzo a pena fixada em metade, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06,

totalizando dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa.

Não é cabível redução maior em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido

Consigno que, embora haja notícia nos autos de que o réu teve passagem por ato infracional enquanto adolescente (fls. 102), o fato ocorreu em 2009, ou seja, há pelo menos doze anos, não podendo, pois, obstar o reconhecimento do privilégio, porquanto não indica que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja "suficiente".

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu EVERTON MUNHOZ DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pelo DEFENSOR foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pelo(a) Representante do MP foi dito que DESEJA RECORRER da sentença.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

- 1) Recebo os recursos interpostos.
 - 2) Dê-se vista ao MP para razões de apelação.
 - 3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.
 - 4) Com as razões de apelação do MP, dê-se vista às Defensoria Pública para contrarrazões.
 - 5) Juntadas as razões da Defesa, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.
 - 6) Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.
 - 7) Com as razões e contrarrazões de recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 12/04/2042.
- Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]